

1500634-29.2021.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Vistos.

GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira - SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500634-29.2021.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-29.2021.8.26.0666

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Vistos.

GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos melhor descritos na exordial acusatória de fls. 02/03.

O réu foi notificado (fl. 77) e, por meio de seu Defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 79/81).

O recebimento da denúncia ocorreu em 15/10/2021 (fl. 84) e o réu foi citado.

Durante a instrução foi inquirida uma testemunha, tendo o réu, ao final, sido

interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva.

A Defesa, por sua vez, requereu o afastamento da causa de aumento e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou demonstrada por meio do laudo químico-toxicológico de fls. 55/56, que atestou pericialmente ser cocaína a substância trazida pelo acusado, estando relacionada na Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998.

A autoria delitiva, de igual sorte, é indubitável.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos. Disse que realmente estava traficando drogas no momento em que foi detido, sendo que trazia consigo onze pedras de crack escondidas em sua boca. Já havia vendido outras drogas anteriormente.

A versão por ele apresentada encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis por sua detenção, os quais confirmaram que o réu estava no Campo do Rapadão - área de lazer -, local assaz conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas, tendo sido abordado por ser conhecido como pessoa envolvida no comércio espúrio e por ter demonstrado nervosismo. Os depoentes encontraram onze porções de crack escondidas em sua boca e R\$ 168,00 em notas de diversos valores. O réu disse que estava traficando drogas no local, o qual é utilizado para a prática de atividades recreativas e esportivas.

Conforme se vê, os policiais lograram êxito em localizar, com o réu, 11 porções de crack, todas já embaladas de forma individualizada (vide foto de fl. 24), prontas para serem entregues ao consumo de terceiros, tendo ele próprio confessado o intuito mercantil que daria às drogas, bem como reconhecido que já havia comercializado outras porções antes de ser detido, razão pela qual fora apreendido o valor de R\$ 168,00 em dinheiro em seu poder.

A própria conduta do réu estar em local conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas, de ter sido detido escondendo em sua boca 11 pedras de crack e de ter afirmado que o considerável valor em dinheiro encontrado consigo era fruto do anterior comércio de entorpecentes são circunstâncias que afastam qualquer alegação de que ele seria mero usuário.

Ressalte-se, no mais, ser despiciendo para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja surpreendido efetivamente comercializando as substâncias ilícitas, tendo o legislador feito expressa menção ao simples ato de o indivíduo "trazer consigo" o entorpecente, desde que haja a finalidade de comercializá-lo a terceiros, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 deve incidir ao caso em apreço, haja vista ter o réu sido preso no exato momento em que trazia consigo 11 pedras de crack, as quais seguramente seriam destinada às pessoas que se encontravam no local dos fatos, o qual é utilizado para a prática de esportes, recreação e atividades sociais.

Apesar da divergência jurisprudencial sobre a questão, e alterando meu anterior posicionamento sobre o tema, reputo que referida majorante tem caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas dependências ou imediações de um dos estabelecimentos mencionados no referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

"Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pena. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Dupla reincidência específica corretamente majorada na fração de 1/3. Causa de aumento do artigo 40 inciso III, da Lei Antidrogas, em razão existência de escola e hospital nas imediações. Incidência. Causa de aumento que tem natureza objetiva. Mantido o acréscimo de 1/5. Regime inicial fechado mantido. Ação revisional julgada parcialmente procedente".

(TJSP; Revisão Criminal 2238080-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª

Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA POR CONTA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

VI - Por fim, "segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (HC n. 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/11/2019). In casu, a Corte de origem atestou que o comércio espúrio ocorria nas imediações de um estabelecimento de ensino. Desse modo, a alteração do julgado, como requerido na impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus".

(STJ - HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Superadas tais questões, resta apreciar o cabimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso em apreço, mostra-se inviável seu reconhecimento, haja vista se tratar de réu reincidente (conforme certidão de fls. 88/89).

Passo, então, à fixação da pena corporal a ser aplicada ao réu, com observância do sistema trifásico adotado pelo Código Penal (artigo 68).

Na primeira fase, em respeito ao que determina o artigo 42 da Lei de Drogas e ao artigo 59 do Código Penal, reputo desfavorável a circunstância relativa à natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), que é das mais prejudiciais à saúde humana, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Na segunda fase, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão, haja vista haver duas condenações criminais pretéritas hábeis a configurar tal agravante, razão pela qual fixo a pena provisória em 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, III, da LD, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a reprimenda definitiva em 7 anos 11 meses e 8 dias de reclusão, e 793 dias-multa.

Registro que o fato de a reincidência do réu ter sido utilizada para agravar a pena e, também, para impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas não implica bis in idem.

Isso porque, conforme entendimento do qual compartilho, na segunda fase da aplicação da pena a reincidência é considerada para a finalidade de aumentar a pena a ser imposta ao agente, enquanto que, na terceira fase, a reincidência é considerada como forma de se impedir que o agente que não seja o traficante pequeno e eventual seja beneficiado com dispositivo legal idealizado para os indivíduos que ostentem bons antecedentes e passado criminal incólume.

Nesse sentido:

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - Impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Aumentos justificados - Bis in idem não verificado - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas

- Regime fechado que deve ser mantido - Recursos improvidos (voto n. 39223)".
(TJSP; Apelação Criminal 0052211-67.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves;
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda
- 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019)

Dada a falta de elementos probatórios acerca da situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, haja vista que o quantum da pena imposta e a presença da circunstância agravante da reincidência recomendam referido regime como o único cabível ao caso em apreço, conforme prevê o artigo 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do CP.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude da quantidade de pena imposta.

Inviável, pelo mesmo motivo, a concessão do sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena corporal de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que estivera preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista se tratar de pessoa reincidente na prática de crime grave, sendo certo que a ordem pública se veria ameaçada caso lhe fosse permitido retornar ao convívio social neste momento, fundamento suficiente para que permaneça segregado cautelarmente (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD), à Secretaria Nacional Antidrogas e à instituição financeira competente, para as providências cabíveis.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ), com a posterior expedição da respectiva Guia de Recolhimento.

Custas na forma da lei, suspendendo-se sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Artur Nogueira, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA